AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006325-17.2015.4.04.0000/RS

RELATOR	:	**Des. Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ**
AGRAVANTE	:	**KAILANE D ÁVILA DA ROSA**
ADVOGADO	:	**Leisi Jaciara Paier**
AGRAVADO	:	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
ADVOGADO	:	**Procuradoria Regional da PFE-INSS**

D.E.

Publicado em 20/04/2016

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RENDA DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE.

O auxílio-reclusão é devido nas mesmas condições da pensão por morte. Isto significa que, naquilo em que aplicáveis, as disposições que regem esta última (arts. 74 a 79 da Lei 8213/91) estendem-se àquele. 2. A concessão do auxílio-reclusão depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 1º) efetivo recolhimento à prisão; 2º) condição de dependente de quem objetiva o benefício; 3º) demonstração da qualidade de segurado do preso, e 4º) renda mensal do segurado inferior ao limite estipulado. 3. Em 25/03/2009, ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos RE 587.365 e RE 486.413, que a renda a ser considerada para a concessão do auxílio-reclusão de que trata o art. 201, IV, da CF, com a redação que lhe conferiu a EC 20/98, é a do segurado preso e não a de seus dependentes, conforme se extrai do Informativo n.º 540/STF. O último requisito pode ser relativizado, tal como a jurisprudência deste Tribunal já adotou em relação ao benefício assistencial, a fim de garantir uma vida digna daqueles que dependem do segurado e se encontram, abruptamente, desprovidos de qualquer renda.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Colenda 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, **dar provimento ao agravo de instrumento**, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 12 de abril de 2016.

Desembargador Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está

disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **8168523v3** e, se solicitado, do código CRC **9B0B2A66**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Paulo Afonso Brum Vaz

Data e Hora: 13/04/2016 16:54

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006325-17.2015.4.04.0000/RS

RELATOR	**:**	**Des. Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ**
AGRAVANTE	**:**	**KAILANE D ÁVILA DA ROSA**
ADVOGADO	**:**	**Leisi Jaciara Paier**
AGRAVADO	**:**	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
ADVOGADO	**:**	**Procuradoria Regional da PFE-INSS**

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária objetivando a concessão de auxílio-reclusão, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.

Assevera a agravante que restaram demonstrados os requisitos para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, na qualidade de filha do segurado apenado. Alega que é menor (11 anos) e, portanto não possui qualquer renda, além de a mãe estar desempregada. Seu genitor era pobre e, inobstante a alegada renda, atualmente está passando necessidade. Em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser concedida a antecipação de tutela, pois presente a verossimilhança da alegação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O pedido de antecipação da pretensão recursal foi deferido (fls. 37-39).

A parte agravada não apresentou contraminuta.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso (fls. 43-44).

É o relatório.

VOTO

Para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ou antecipação da pretensão recursal, necessário se verifique a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação.

É cediço que o benefício de auxílio-reclusão independe de carência, a teor do que prescreve o art. 26, inciso I, da Lei n.º 8.213/91. Quanto aos demais requisitos, cumpre seja observado o disposto no art. 80 da referida Lei de Benefícios.

Assim, além do efetivo recolhimento à prisão, exige-se a comprovação da condição de dependente de quem objetiva o benefício, bem como a demonstração da qualidade de segurado do segregado, o que se verifica preenchido na espécie.

Com o advento da Emenda Constitucional n.º 20, de 15-12-1998, contudo, a concessão da referida benesse restou limitada às famílias de baixa renda.

Com efeito, a tal respeito se vinha entendendo que o limite a que se refere a EC n.º 20/98 deve guardar relação com a renda do grupo familiar beneficiário, e não com o último salário-de-contribuição do segurado, tendo o Decreto n.º 3.048/99, e as seguintes atualizações, extrapolado a sua função regulamentadora.

Todavia, em 25/03/2009, ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE 587.365 e RE 486.413 que a renda a ser considerada para a concessão do auxílio-reclusão de que trata o art. 201, IV, da CF, com a redação que lhe conferiu a EC 20/98, é a do segurado preso e não a de seus dependentes, nos seguintes termos:

> *"PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 201, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DOS CONTEMPLADOS PELO AUXÍLIO-RECLUSÃO. BENEFÍCIO RESTRITO AOS SEGURADOS PRESOS DE BAIXA RENDA. RESTRIÇÃO INTRODUZIDA PELA EC 20/1998. SELETIVIDADE FUNDADA NA RENDA DO SEGURADO PRESO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I - Segundo decorre do art. 201, IV, da Constituição,* ***a renda do segurado preso é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus dependentes****. II - Tal compreensão se extrai da redação dada ao referido dispositivo pela EC 20/1998, que restringiu o universo daqueles alcançados pelo auxílio-reclusão, a qual adotou o critério da seletividade para apurar a efetiva necessidade dos beneficiários. III - Diante disso, o art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da inconstitucionalidade. IV - Recurso extraordinário conhecido e provido." (grifei)*
> *(RE 587365, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-084 DIVULG 07/5/2009 PUBLIC 08/5/2009 EMENT VOL-02359-08 PP-01536).*
>
> *"PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 201, IV, DA CF. DESTINATÁRIO. DEPENDENTE DO SEGURADO. ART. 13 DA EC 20/98. LIMITAÇÃO DE ACESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Nos termos do art. 201, IV, da CF, o destinatário do auxílio-reclusão é o dependente do segurado recluso. II - Dessa forma, até que sobrevenha lei, somente será concedido o benefício ao dependente que possua renda bruta mensal inferior ao estipulado pelo Constituinte Derivado, nos termos do art. 13 da EC 20/98. III - Recurso extraordinário conhecido e provido."*
> *(RE 486413, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2009, DJe-084 DIVULG 07/05/2009 PUBLIC 08/05/2009 EMENT VOL-02359-06 PP-01099).*

Porém, o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito devido à elevada cultura jurídica de seus membros, operou em equívoco na solução que ofereceu à interpretação do art. 201, IV, da Constituição da República. O princípio da seletividade e distributividade das prestações e serviços da seguridade social não tende a ser adequadamente aplicado quando se

leva em conta fatores ou critérios desvinculados do grau de necessidade do destinatário da prestação da seguridade social.

Se o benefício se deve aos dependentes que, de súbito, vêem-se desprovidos de meios de subsistência pela reclusão do segurado, é ilógico medir a sua necessidade pela remuneração mensal do segurado, remuneração esta já inexistente a partir da reclusão.

Mas na medida em que o STF, desprezando a inteligência do art. 13 da EC 20/98 na forma referida no estudo de caso anterior, expressa que o direito do dependente à provisão de sua subsistência depende do valor da remuneração mensal do segurado que não mais existe, torna-se indispensável, nos casos em que demonstrada a necessidade do conjunto de dependentes, a flexibilização do limite da remuneração mensal do segurado recluso, à semelhança do que restou consagrado pela jurisprudência em relação à relativização do critério econômico do benefício assistencial.

Se não for assim, teremos de admitir que a circunstância de a remuneração mensal do segurado recluso ser pouco superior ao limite do que se considera baixa renda poderia lançar menores dependentes à margem de qualquer proteção previdenciária.

Interessante notar que a dependência econômica dos dependentes da classe prioritária é presumida, do que se poderia extrair a viabilidade da relativização do critério econômico pela presunção de necessidade de meios externos de subsistência. Mas a relativização da remuneração mensal parece apenas justificada se, no caso concreto, restar comprovada a necessidade urgente que reafirma a presumida dependência econômica.

Note-se que raciocínio semelhante foi adotado pelo STF quando admitiu que o critério objetivo de renda mensal familiar per capita de 1/4 do salário-mínimo, definido em lei, era insuficiente para definir os casos de necessidade de proteção à pessoa idosa ou com deficiência (Reclamação 4374, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.04.2013, DJ 04.09.2013).

Justamente no sentido que aqui é sustentado, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Primeira Turma, em julgamento proferido à unanimidade de votos:

> *RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO ABSOLUTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREVALÊNCIA DA FINALIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.*
> *1. O benefício de auxílio-reclusão destina-se diretamente aos dependentes de segurado que contribuía para a Previdência Social no momento de sua reclusão, equiparável à pensão por morte; visa a prover o sustento dos dependentes, protegendo-os nesse estado de necessidade.*
> *2. À semelhança do entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.112.557/MG, Representativo da Controvérsia, onde se reconheceu a possibilidade de flexibilização do critério econômico definido legalmente para a concessão do Benefício Assistencial de Prestação Continuada, previsto na LOAS, é possível a concessão do auxílio-reclusão quando o caso concreto revela a necessidade de proteção social, permitindo ao Julgador a flexibilização do critério econômico para deferimento do benefício, ainda que o salário de contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda.*
> *3. No caso dos autos, o limite de renda fixado pela Portaria Interministerial, vigente no momento de reclusão da segurada, para definir o Segurado de baixa-renda era de R$ 710,08,*

ao passo que, de acordo com os registros do CNIS, a renda mensal da segurada era de R$ 720,90, superior aquele limite 4. Nestas condições, é possível a flexibilização da análise do requisito de renda do instituidor do benefício, devendo ser mantida a procedência do pedido, reconhecida nas instâncias ordinárias.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.
(REsp 1479564/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 06/11/2014, DJe 18/11/2014).

Trata-se de um claro exemplo de como a jurisdição previdenciária, ligada que é às noções de mínimo existencial e de provisão de recursos indispensáveis para subsistência digna, não se encontra sob o jugo aleatório das expressões matemáticas ou das diretrizes normativas que não podem prever as imperfeições ou particularidades de determinados problemas concretos.

É de se recordar que o direito à concessão de um benefício da seguridade social não pode ser aferido a partir dos critérios milimétricos estabelecidos pela legislação. O direito à proteção social para subsistência não se expressa de um modo matemático. Mais particularmente, os problemas de sobrevivência que se apresentam em um processo previdenciário não serão adequadamente solucionados desde uma perspectiva positivista, no sentido de serem os requisitos postos à evidência do juiz.

Se está em jogo o bem-estar humano; se a contingência social (que pode acometer a qualquer pessoa pelo só fato de viver em sociedade) transforma-se em fator com potencialidade para colocar uma generalidade de pessoas em uma situação de desvantagem - e até mesmo de lhes suprimir as condições de obter recursos a partir de seus esforços pessoais -, a imediata compensação social se justifica em nome da igualdade e com vistas à promoção da autonomia pessoal, elementos constitutivos da dignidade humana. Se o direito fundamental aos meios de subsistência em situação de adversidade encontra-se esvaziado porque o sistema normativo oferece proteção deficiente a este direito fundamental - seja por omissão, seja por desproporcional condicionante de acesso à proteção -, o princípio da universalidade da proteção humana contra riscos sociais encontra-se vulnerado.

Corolário da eficácia normativa do princípio da universalidade da proteção humana contra riscos sociais, o Poder Judiciário deve fazer cessar a omissão inconstitucional decorrente da proteção deficiente do direito fundamental à proteção social. Da mesma forma, com fundamento no princípio da proibição de proteção deficiente, deve-se afastar condicionante legal que, em determinadas circunstâncias, afigura-se desproporcional e culmina por comprometer a própria finalidade do sistema protetivo, qual seja, a de oferecer proteção à vida humana que se encontra em uma contingência social adversa.

Dito isso, tenho que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, considerando que a negativa se deu em razão de o último salário de contribuição ter extrapolado o valor previsto na legislação. Ora, embora o último valor recebido tenha correspondido, no mês de março/2015, a R$ 1.663,12 (fl. 26), é de ser considerado, no caso em comento, como amplamente justificado acima, a condição de miserabilidade da dependente, menor de idade (nascimento em 2014), aliado, ainda, ao fato de que a mãe está desempregada, conforme cópia de CTPS acostada às fls. 27/29.

Por sua vez, o perigo de dano irreparável resta caracterizado na natureza alimentar do benefício, aliado à grande possibilidade de ser causado prejuízo à sobrevivência

da autora, caso deva aguardar o desfecho da lide para recebimento dos valores pleiteados.

Por fim, destaca-se que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser realizada sem a providência antecipatória.

Em face do exposto, **voto por dar provimento ao agravo de instrumento para determinar que o INSS implante o benefício de auxílio-reclusão em favor da autora no prazo de 30 dias**, nos termos da fundamentação.

Desembargador Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **8168521v2** e, se solicitado, do código CRC **E154D52A**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Paulo Afonso Brum Vaz
Data e Hora:	13/04/2016 16:54

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 12/04/2016

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006325-17.2015.4.04.0000/RS
ORIGEM: RS 00030428720158210158

RELATOR	:	Des. Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ
PRESIDENTE	:	Paulo Afonso Brum Vaz
PROCURADOR	:	Dr. Marcus Vinícius Aguiar Macedo
AGRAVANTE	:	KAILANE D ÁVILA DA ROSA
ADVOGADO	:	Leisi Jaciara Paier
AGRAVADO	:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO	:	Procuradoria Regional da PFE-INSS

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 12/04/2016, na seqüência 97, disponibilizada no DE de 22/03/2016, da qual foi intimado(a) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a DEFENSORIA PÚBLICA e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 5ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DETERMINAR QUE O INSS IMPLANTE O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO EM FAVOR DA AUTORA NO PRAZO DE 30 DIAS, TENDO O DES. FEDERAL ROGERIO FAVRETO APRESENTADO RESSALVA

DE ENTENDIMENTO PESSOAL.

RELATOR ACÓRDÃO	:	Des. Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ
VOTANTE(S)	:	Des. Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ
	:	Des. Federal ROGERIO FAVRETO
	:	Juiz Federal LUIZ ANTONIO BONAT

Lídice Peña Thomaz
Secretária de Turma

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Destaque da Sessão - Processo Pautado

Ressalva em 11/04/2016 18:15:21 (Gab. Des. Federal ROGERIO FAVRETO)
Acompanho o relator, com ressalva quanto aos limites de rendado segurado na época da prisão.
(Magistrado(a): Des. Federal ROGERIO FAVRETO).

Documento eletrônico assinado por **Lídice Peña Thomaz, Secretária de Turma**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **8257731v1** e, se solicitado, do código CRC **F889CBA7**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Lídice Peña Thomaz
Data e Hora:	13/04/2016 14:50